

1500220-35.2022.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500220-35.2022.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500220-35.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087934/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 23976250 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2087934 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2087934 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARMEM SILVIA LOPES DO NASCIMENTO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

FLÁVIO ROBERTO DE JESUS PEREIRA e CARMEM SILVIA LOPES DO NASCIMENTO, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 30 de março de 2021, por volta das 20horas, na Praça Irmãos Ferreira, nº1, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo para fins de tráfico, 18,80 gramas (dezoito gramas e oitenta decigramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", na forma de 08 (oito) porções em embalagens de plástico transparente (auto de exibição e apreensão a fls. 12 e laudo químico- toxicológico a fls. 32/35), substância entorpecente que determina

dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que no dia 30 de março de 2021, por volta das 20 horas, na Praça Irmãos Ferreira, nº 1, nesta cidade e comarca de Cerqueira César, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, associaram-se, de maneira estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas. Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/48. Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares aos réus (fls. 66/69). Alvarás de soltura cumpridos a fls. 77/80. Os réus foram notificados (fls. 119 e 121) e ofereceram defesa preliminar (fls. 126/130 e 146/148). Por decisão proferida em 25 de maio de 2022, não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em relação ao réu Flávio (fls. 131/132). A ré ofereceu defesa preliminar (fls. 146/148). Recebida denúncia em 02 de junho de 2022 em relação a ré Carmem e sobreveio a designação de audiência (fls. 149/150). Os réus foram citados a fls. 189 e 191. Em audiência, foi inquirida uma testemunha em comum e os réus interrogados (fls. 209/211 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a parcial procedência da ação, pugnano pela condenação dos réus somente no crime de tráfico de drogas (fls. 209/211). Por sua vez, a douta defesa da ré pugnou pela absolvição quanto à prática do crime associação com fundamento no artigo 386, incisos II do CPP e, em relação ao crime de tráfico pleiteou o reconhecimento do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela fixação do regime inicial aberto com a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e pela possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 212/215). Já a douta Defesa do réu pugnou pela sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e, em caso de condenação que seja aplicada a pena no mínimo legal, o reconhecimento de tráfico privilegiado e regime inicial aberto (fls. 216/221).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, " na data dos fatos, policiais militares receberam a informação de que um casal estaria vendendo entorpecentes na Praça central da Matriz. Segundo as informações, a mulher guardava o entorpecente e reabastecida o comparsa, enquanto ele realizava a venda. Os policiais se dirigiram ao local e avistaram o casal. Realizaram abordagem e, em revista pessoal, com FLÁVIO ROBERTO encontram duas porções de "maconha", dentro de um maço de cigarro. Já CARMEM entregou aos policiais 6 (seis) porções do mesmo entorpecente. Questionados pelos militares, FLÁVIO ROBERTO admitiu os fatos, dizendo que um indivíduo conhecido por "JB" passava de hora em hora pelo local recolhendo o dinheiro da venda e repondo o estoque de entorpecentes. CARMEM disse que escondeu as porções do colega com receio de que ele fosse preso. Por conta disso, FLÁVIO ROBERTO e CARMEM foram presos em flagrante delito. ". Assim, diante das circunstâncias, do acondicionamento, da quantidade e da forma em que os entorpecentes foram encontrados, restou demonstrado de maneira límpida que as drogas se destinavam ao comércio ilícito".

Examinada a questão à luz da prova produzida, verifico que a pretensão punitiva estatal merecer ser julgada parcialmente procedente, uma vez que não se comprovou a prática do delito de associação para o tráfico.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou configurada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória a fls. 32/35, fotografias a fls. 36/37, laudo toxicológico definitivo a fls. 105/108, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre os réus. A testemunha de acusação Marcos Jean do Amaral, policial militar, em juízo, contou " receberam informações acerca de um casal vendendo drogas na Praça. Dirigiram-se até o local, localizaram os acusados e mantiveram distância para observar o casal. Segundo as informações obtidas , a ré guardava a droga e repassava aos poucos a droga para Flávio, porque caso ele fosse pego, possivelmente seria um porte e no

caso dela, dificilmente esta seria abordada. Realizaram a abordagem no acusado e foi encontrada pouca quantidade de entorpecente. Indagada ela disse que não tinha nada, entretanto, no momento em que disseram que seria chamada uma policial feminina para fazer a revista, a acusada entrou a droga. Ela disse que a droga seria dele e esta só estava guardando para ele não ser preso. Disse que receberam a informação no dia dos fatos, por uma pessoa que os parou na rua e informou que na praça tinha um casal , um rapaz alto, moreno , magro e uma senhora com roupa florida e sapato rosa. Relatou que é a praça é local conhecido por venda de drogas."

A ré Carmem Sílvia Lopes do Nascimento, em seu interrogatório judicial, contou " que estava em sua casa e tem um filho que é usuário de drogas, o qual tinha em sua posse uma quantidade de maconha em pedaços. Relatou que estava passando por dificuldades financeiras e resolveu vender a droga na praça. Disse que vendeu as duas porções de maconha ao Flávio, momento em que a polícia chegou. Negou que ele estivesse vendendo drogas com ela."

O réu Flávio Roberto de Jesus Pereira, em juízo, disse " no dia dos fatos , foi até a praça para comprar baseado. No caminho encontrou com a Dona Carmem e perguntou se ela tinha entorpecente para vender. Relatou que na Delegacia assumiu que estava traficando porque ficou nervoso e resolveu livrar a ré, em razão dela ser idosa. Entretanto, era ela quem estava vendendo e este somente comprou o entorpecente". Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelos réus. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, das circunstâncias da prisão, do modo pelo qual estava acondicionada e as informações de civis que a polícia recebeu que ambos estavam vendendo entorpecentes da praça. Com efeito, inobstante a confissão parcial da corré Carmem admitindo que praticava sozinha o tráfico de drogas, entendo que essa alegação é desprovida de um mínimo de veracidade em cotejo com as demais provas constantes dos autos. Observa-se, tão somente, mais uma tentativa inexitosa de livrar o réu Flávio das imputações. Nesse contexto, as versões dos réus, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceram de todo isolada no contexto probatório, já que nada produziram, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

Neste ínterim, ressalte-se que o policial, em depoimento uníssono ao prestado na delegacia confirmou em juízo a dinâmica da prisão. Suas declarações foram, em essência, coerentes e harmônicas. É de se asseverar que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a presar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não se evidenciou nestes autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.)

...

"Não se pode 'a priori', negar valor a depoimento de policial, pois todo cidadão

tem a seu favor a presunção de honestidade, máxime quando exerce função pública de relevo. Como qualquer outro, o testemunho policial sujeita-se à análise crítica do julgador, que lhe dará o valor probante que merecer" – Relator Juiz João Guzzo, citado por J.L. de Azevedo Franceschini – Tóxicos – fls. 215). Considere-se ainda que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria consagrar a total impunidade.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em depósito ou trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, eis que forma em que estava acondicionada a droga, além da informação recebida pelos policiais de que um casal estava vendendo entorpecentes na praça, é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De maneira diversa, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não prova acerca do suposto "animus" associativo entre os réus. Evidenciou-se mais um caso de concurso de pessoas, já que não restou comprovado nestes autos a estabilidade e permanência do tráfico em conjunto. Nesse sentido vem ensinando a doutrina: "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira societas sceleris que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743) (destaquei)

Por fim, no que tange aos argumentos Defensivos, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação, são eles precários, insubsistentes e revelam-se desamparados ante o quadro acusatório firmemente consolidado nos autos. Em verdade, a simples alegação de ausência de provas não é suficiente para afastar a responsabilidade imputada, carecendo de um mínimo qualquer de credibilidade a

autodefesa, destituída que foi e é de qualquer alicerce. Ademais, não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus CARMEM SILVIA LOPES DO NASCIMENTO e FLÁVIO ROBERTO DE JESUS, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal. Por outro lado, ABSOLVO os réus CARMEM SILVIA LOPES DO NASCIMENTO e FLÁVIO ROBERTO DE JESUS, já qualificados, da imputação que lhes foi feita como incurso no art. 35, "caput", da lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação ao réu Flávio Roberto de Jesus. atento aos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e à sua primariedade (F.A. e certidões a fls. 51/52 e 58), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, portanto, mantenho a pena anteriormente aplicada. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de que participe ou integra associação e/ou organização criminosa, faço a diminuição de 2/3 (dois terços). Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Em relação à ré Carmem Silvia Lopes do Nascimento, atento aos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e à sua primariedade (F.A. e certidões a fls. 49/50 e 56/57), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, vez que a pena já fora fixada em seu patamar mínimo legal. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e não há nos autos notícias de que participe ou integra associação e/ou organização criminosa, faço a diminuição de 2/3 (dois terços). Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal. DIAS-MULTA.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO para ambos os réus, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, os réus poderão apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA